

《【문제17.3】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하여 제1심에서 승소하였다. 乙은 이에 불복하여 항소하였으나 항소심에서도 패소하였고, 상고를 제기하였으나 대법원에서 상고기각 판결이 선고되어 2023. 8. 1. 판결이 최종 확정되었다. 이후 2024. 9. 1. 乙은 항소심 당시 자신의 소송대리인이었던 A가 상대방 甲과 공모하여 乙에게 불리한 진술을 하는 등 대리권의 흠결이 있었음을 알게 되었다.

乙은 2024. 9. 20. 항소심 판결에 대하여 재심의 소를 제기하고자 한다. 그런데 확인 결과 乙은 항소심 재판 과정에서 이미 A의 대리권 행사에 문제가 있음을 인지하고 항소이유서 등에 이를 언급하며 다툰 사실이 있었다. 또한 乙은 항소심 판결뿐만 아니라 대법원의 상고기각 판결에 대해서도 재심사유가 존재한다고 동시에 재심을 제기하려 한다.

한편, 丙은 丁을 상대로 한 소송에서 `화해권고결정`을 받아 확정되었으나, 이후 그 결정의 기초가 된 증거가 위조되었음을 발견하였다. 丙은 일반적인 판결에 대한 재심 절차에 따라 화해권고결정에 대한 재심의 소를 제기할 수 있는지 여부를 고민하고 있다.

(물음1) 乙이 주장하는 재심사유인 `대리권의 흠결`이 민사소송법 제451조 제1항 단서의 보충성 원칙에 위배되는지 여부를 乙이 항소심에서 이를 주장하였던 사정과 관련하여 논하고, 항소심 판결과 상고기각 판결이 모두 존재하는 경우 재심 대상의 확정(재심의 소의 대상)에 관한 원칙을 설명하시오.》

<문제17.3의 물음1> 재심사유의 보충성 원칙 위배 여부 및 재심대상의 확정 원칙

I. 문제의 제기

-사안에서 乙은 항소심에서 이미 소송대리인의 대리권 흠결을 주장하였음에도 이를 재심사유로 항소심 판결에 대한 재심을 제기하고, 상고기각 판결에 대해서도 함께 재심을 구하려는 상황이다. 쟁점으로 <대리권의 흠결이 민사소송법 제451조 제1항 단서의 보충성 원칙에 위배되는지>와 <항소심 판결 및 상고기각 판결이 모두 존재하는 경우 재심의 소의 대상을 어느 판결로 확정할 것인지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 재심사유의 보충성 원칙 위반 여부와 재심의 소의 대상이 되는 판결을 설명한다.

II. 재심사유의 보충성 원칙

1. 보충성 원칙의 의의

-재심의 소는 상소에 의하여 구제받을 수 없었던 경우에 한하여 허용되는 최후의 수단이다. 따라서 "민사소송법 제451조 제1항 단서"에 의하여 당사자가 상소에 의하여 재심사유를 주장하였거나, 상소 제기 당시에 그 사유를 알고 있었음에도 불구하고 이를 주장하지 않은 경우에는 재심의 소를 제기할 수 없다.

2. 대리권 흠결과 보충성 원칙

(1) 원칙적 적용

-재심사유 중 법정대리권·소송대리권의 흠결은 "민사소송법 제451조 제1항 제3호"에 해당한다. 만약 당사자가 판결 확정 전의 소송절차에서 대리권의 흠결을 알고 있었고 이를 충분히 주장할 수 있었음에도 불구하고 주장하지 않았다면, 판결 확정 후 이를 이유로 재심을 제기하는 것은 보충성 원칙에 반하여 허용되지 않는다.

(2) 사안의 특수성

-사안에서 乙은 항소심 재판 과정에서 이미 A의 대리권 행사에 문제가 있음을 인지하였고, 항소이유서 등을 통해 이를 언급하며 다툰 사실이 있다. 이는 당사자가 상소 절차에서 해당 사유를 이미 주장한 경우에 해당하므로, 법문의 취지상 동일한 사유를 내세워 다시 재심을 제기하는 것은 보충성 원칙에 위배될 소지가 크다.

III. 재심대상의 확정(재심의 소의 대상)

1. 기본 원칙

-재심은 원칙적으로 확정된 종국판결을 대상으로 한다. 그러나 하나의 사건에 대하여 제1심, 항소심, 상고심 판결이 순차적으로 내려져 모두 확정된 경우, 어느 판결을 재심대상으로 삼을 것이냐가 문제된다.

2. 심급에 따른 대상 확정

(1) 항소심 판결과 상고심 판결의 관계

-본안에 대하여 항소심 판결이 있고 이에 대한 상고가 기각되어 상고심 판결이 확정된 경우, 재심의 대상은 원칙적으로 본안판결인 항소심 판결이 된다. 상고심의 상고기각 판결은 하급심 판결의 당부를 심사하여 이를 유지하는 것이므로, 실질적인 판단의 기초가 된 항소심 판결에 재심사유가 있다면 항소심 판결을 대상으로 재심을 제기해야 한다.

(2) 상고심 판결 자체가 대상이 되는 경우

-만약 재심사유가 항소심 판결에는 없고 오직 상고심의 소송절차나 상고심 판결 자체에만 존재하는 경우(예 : 상고심에서의 판단누락 등)에는 예외적으로 상고심 판결을 대상으로 재심을 제기할 수 있다.

(3) 흡수설과 독립설의 태도

-`판례`는 원칙적으로 하급심 판결이 상급심 판결에 의하여 확정된 경우, 하급심 판결에 재심사유가 있다면 하급심 판결을 대상으로 재심을 제기해야 한다는 입장이다. 다만, 상고심에서 본안판결을 한 경우(상고기각이 아닌 파기자판 등)에는 상고심 판결이 대상이 된다. 사안과 같이 상고기각 판결로 항소심 판결이 확정된 경우에는 항소심 판결이 재심의 대상이 되는 것이 원칙이다.

IV. 사안의 적용

1. 보충성 원칙 위배 여부

-사안의 乙은 항소심 과정에서 소송대리인 A의 대리권 흠결 문제를 인지하였고 이를 항소이유서에서 주장하며 다투었다. 이는 "민사소송법 제451조 제1항 단서"의 상소에 의하여 그 사유를 주장한 때에 해당한다. 재심은 상소로 구제받지 못한 경우에 한하여 보충적으로 허용되는 것이므로, 이미 항소심에서 심리되었거나 주장되었던 사유를 다시 재심사유로 삼는 것은 보충성 원칙에 위배되어 부적법하다.

2. 재심대상의 확정

- 乙은 항소심 판결과 상고기각 판결에 대하여 동시에 재심을 제기하려 한다. 대리권의 흠결이라는 사유가 항소심 변론 과정에서의 행위에 기인한 것이라면, 재심의 대상은 실질적인 심리가 이루어진 항소심 판결이 되어야 한다. 상고심 판결은 법률심으로서 항소심 판결을 확정시킨 것에 불과하므로, 항소심 절차상의 하자를 이유로 상고심 판결에 대해 재심을 제기하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 따라서 乙은 항소심 판결을 대상으로 재심을 제기하여야 하며, 상고기각 판결에 대한 재심은 특별한 사유(상고심 자체의 하자)가 없는 한 대상적격이 인정되기 어렵다.

V. 결론

- 사안의 乙이 주장하는 대리권 흠결 사유는 이미 항소심에서 주장된 바 있으므로 보충성 원칙에 위배되어 재심사유로 삼을 수 없다. 또한 재심대상 확정에 있어서는 실질적 판단의 기초가 된 항소심 판결이 대상이 되어야 하며, 상고기각 판결은 원칙적으로 재심의 대상이 될 수 없다.